徽剑案刑罚辨

夫刑者，天下之公器也。轻重有法，出入有据，所以惩已然之恶，而禁未然之奸也。苟罪重而刑轻，则恶者幸其可逭；刑重而证薄，则良者惧其无辜。二者皆失刑之本意。故论刑者，不可徒徇众怒，亦不可徒守成说；必审其事，核其罪，究其情，辨其法，而后轻重之义可明。

近有吴恺者，号曰“徽剑”，尝以文章揭境外电信诈骗之弊。其所指斥者，非寻常市井之奸，而有据海外、聚徒众、谋厚利者。甲辰年十一月，吴恺忽为人劫持，辗转数地，屡遭暴行，终被弃于江西荒山而死。案经广东惠州中院审理，以赵冰为主犯，论故意伤害致死，判死刑，缓期二年执行。其余十三人，依所犯各受其刑。丙午年八月，广东高院终审，维持原判。

裁定至十月下旬广为人知，天下哗然。

众人所疑者，非谓凶犯无罪，亦非谓死缓不重，乃谓如此恶行，何以论罪当死，而犹得缓其执行？其所据以缓死之由，果足服天下乎？

此问不可不辨。

据已披露之裁定，案初有境外之人，托名“少校”，悬金三十万元，招人劫持吴恺，欲迫其吐露消息、删除文章。赵冰应其募，复纠集徒众，所索赏金增至百万元。诸人预谋踩点，伪充警察，公然劫人于惠州，继而转徙广东、江西诸地，逼问施暴。既使吴恺昏迷，复弃之荒僻之所，不施救援。后二日，人始发现其遗体。

此事之可畏，不独在一人之死。

昔之强盗，恃其力而劫财；今之凶徒，受人金而夺命。昔之奸人，避官府而行凶；今则假官府之名，以遂其奸。身在境外者，不必亲临中国，即可遥使境内之徒为其驱策；欲禁人言者，不必据有公权，即可悬赏使人噤声。

其名曰受雇，其实为受财行凶；其名曰查问，其实为非法拘押；其名曰执法，其实为假公权以害民。

此数者相合，则其害不止于被害之人，而及国家法令之威信、百姓人身之安全。使此风得以滋长，则民见捕役，不知其真伪；见人揭奸，不知其能否自全。公权之名，一旦可为奸人所假，则守法之民反有所惧，而犯法之徒益有所恃。此其所以尤当深究者也。

然欲正其罪，必先辨其名。

或曰：“诸人既强劫吴恺，何不以绑架论之？”

曰：世俗所谓绑架，与刑律所定绑架之罪，未必尽同。今刑法以勒索财物而绑人，或劫人为质者，为绑架罪。若受雇于人，强夺他人自由，而非以所拘之人要挟第三者，则虽其形似绑架，未必悉合其法定要件。

此非为凶徒开脱，乃刑律定罪之义不得混淆也。

然则不入绑架之罪，便可轻论乎？亦非也。刑法于非法拘禁之中，已有使用暴力致人伤残、死亡者，依故意伤害、故意杀人之条定罪之规定。故罪名不同，未必刑责遂轻；关键不独在拘人之初意，而尤在施暴之行为及其主观罪过。

夫人之意，非一成而不可变也。

始欲拘之，终或欲杀之；始不欲其死，终或明知其将死而放任之。苟徒执其初意，而不察其后行，则天下欲杀人者，皆可先托拘问之名，以掩其后之杀心矣。

故故意伤害致死与故意杀人之辨，不专在凶犯自言欲何为，而当合其行为、手段、处境、后果及救助可能，察其于死亡之结果，究竟仅有伤害之故意，抑已明知死亡危险而放任其发生。

今案中诸人劫吴恺，辗转远地，屡施暴行，终置其于荒山而不救。此诸行为，固足使人疑其于死亡之结果有所放任。然怀疑之可立，与杀人故意之已获证明，亦不可混为一谈。若证据足明其知死险而容其死，则当依法究其杀人之责；若证据仅足证明故意伤害，而死亡出于其伤害行为所致，则应依法论伤害致死。

不得因凶犯自辩无杀意而遽信之，亦不得因众人愤其恶而径定杀意。所当问者：其行为足以证明何种主观罪过？其证据能否排除合理之疑？法院又何以舍此而取彼？

有其辨而无其证，不可以定罪；有其证而不究其辨，亦不足以服人。

至于死刑之缓否，尤当精察。

今刑法第四十八条，死刑专施于罪行极其严重者；应判死刑而非必须立即执行者，得缓期二年。是故死刑与死缓，固有法定之别。不可谓判死而缓之，即为纵凶；亦不可谓既判死刑，便当然必须立即执行。

然而法律既分其二，则择其一者，亦当明其所以然。

据公开报道，二审法院认赵冰为主犯，且为直接致害之人，论罪应判死刑；惟以被害人自身高血压对死亡有促进作用、赵冰归案后坦白、积极赔偿物质损失等情节，认为死刑可不立即执行。

此三者，果皆足以支持其判断乎?

先论疾病。

据法医鉴定，吴恺之死与外伤直接相关；另有专家咨询意见，谓其高血压对死亡有一定促进作用，建议列为次要死因。

夫人之禀赋有强弱，疾病有轻重，此天下之常情也。若加害于人，遇素健者则伤，遇宿患者则死，岂可因此谓被害之人自有疾病，遂使加害者当然减其责哉?

固不可也。

然亦不可反谓被害者有宿疾，于量刑一概无关。苟其疾病与损害结果之发生，确有独立而重大的因果作用，则于责任评价，自有详察之必要。问题不在有病与无病，而在病之作用究竟为何，外伤与死亡之间的因果关系是否明晰，以及此等因素能否实质影响行为人应受刑罚之判断。

若外伤为致死之主因，宿疾仅助成其结果，则不得以宿疾之存在，掩暴力之根本作用。若欲因宿疾而缓其刑，更须明示其法律理由，不可但举“次要死因”四字，便使轻重之辨无从追问。

况法医鉴定与专家咨询，证据性质、形成程序及证明力量未必尽同。何者为据，何者为辅，何以取信，皆当辨明。

不审其所以死，而徒言其有病，是以名代实也；不辨疾病之作用，而径论刑之轻重，是以疑代证也。

次论坦白。

凶犯归案，如实供述，法律许其从宽，此所以鼓励认罪、节省讼争、查明事实也。其制自有道理。然坦白与自首不同，坦白之深浅、供述之真伪、是否有助查明全案，亦有分别。

使有罪者既归案而陈其所犯，便一概可免死刑立即执行，则坦白之制，岂非足以消解重刑之威？反之，若凡罪重者虽坦白亦绝无从宽之可能，则法律所设从宽之条，又几为空文。

故不可一概从宽，亦不可一概不宽。所当问者，乃其坦白之具体内容、于查案之贡献，以及与本案罪行之严重程度相衡，究竟有多大分量。

今案境外发令之“少校”，据报道其真实身份尚未查明。此固不足反证赵冰未曾如实供述，然其供述究竟足以揭示何事，有无重大隐瞒，是否有助追索幕后主使，皆关系其坦白情节之评价。

坦白有其可宽之理，而不足自明其必当缓死之由。

复论赔偿。

据裁定所载，赵冰经亲属筹集五十万元，交付吴恺有关亲属，且有谅解文书。然二审法院亦明言，此案针对揭露境外电诈者而发，社会危害严重，不应因赔偿、谅解而予以从轻、减轻处罚。

此论诚有可取。

夫赔偿者，救被害者亲属之经济损失也；刑罚者，究犯罪者侵害法益之责任也。二者相关，而不可相代。杀人而有财者，不得以财赎其罪；无财者，亦不应徒以无力赔偿而加其刑。

然法院既称不因谅解而从轻，又于决定死刑是否立即执行时，提及积极赔偿，则尤宜辨明：其所重者，究竟是补偿损失之实际行为，还是亲属出具谅解之意思？赔偿在整体量刑中占何分量？何以虽不足从轻减轻，却足供判断死刑是否必须立即执行之参酌？

二者在法律上未必矛盾，而其分际不可不明。

至于赔款所出何人、何处，若有具体疑点，依法核查可也；若徒因被告之家境不裕、聘请律师、筹得赔款，遂断其必有幕后资助，甚或推言司法受贿，则又过矣。

律师为被告辩护，法定之权利也。即罪大恶极之人，亦不得废其辩护。使一人被控重罪，便以其有律师为可疑，则今日可以废恶人之辩，明日亦可废良人之辩。

惟其权利当保，故其罪责始可正；惟其证据当严，故其判决始可信。

然则本案所当深究者，究竟何在？

曰：不独在一人之死缓，而在境外发令、境内应募、冒充执法、跨地劫持、受财行凶之事，竟能首尾相接，遂成大案。

夫境外之人何以得吴恺住址、车牌与近照？何以能遥纠众徒？何以能以巨金酬其事？居间联络者何人？其金钱往来何由？其幕后主使究竟是谁？

此皆与全案之组织、动机、共犯责任及社会危害相涉。若主使尚未查明，则已判之刑虽终，追查之责未可谓尽。

又诸犯冒充警察而劫人，此尤伤法治之根本。

国家设官，所以禁暴安民也。今奸人假官之名，公然夺人自由，使百姓不辨真伪，则官之名为奸人所窃，而法之信为奸人所损。若民遇真正执法者亦生疑惧，岂不使善治之器反受恶人之累乎？

故此案之治，不惟严刑其人，亦当检视冒充执法身份之识别、核验及救济机制，使民知何者为法，何者为诈；使奸人不得假公权之名而逞私凶。

是以其社会危害之深，不独当计被害人数，亦当计其所侵之公共信赖。

或曰：“既如此，何不立改死刑立即执行，以昭国威？”

曰：国威者，法之威也，非刑之酷也。

刑罚严明，固足禁奸；然重刑之所以可服天下，在其依法而断，证据确实，责任相当。若以人众之怒代法律之审，则今日众怒所向者虽为真凶，异日众怒所向者未必皆有罪。刑律之设，所以防奸人，亦所以防错刑也。

故当从严者，不得假宽仁以纵之；当存疑者，不得因激愤以重之。

至于李昌奎等往案，虽可相参其量刑之义，亦不可见彼案改判死刑，便谓此案必须同判。案件各有事实、证据与法定情节。所可相较者，是同类情节之评价有无一致标准；所不可强同者，是舍其证据而徒取其结果。

今本案二审已终，亦非寻常上诉、抗诉之期可以复用。然终审非谓永不可纠。刑事诉讼法既设审判监督之制，若原裁判确有事实认定错误、证据不足、法律适用错误或足以影响公正之程序瑕疵，上级司法机关自有依法审查、提起再审或审判监督抗诉之途。

故欲推动改判者，当明指其错，举证其失，依法求其审，而不宜徒以呼声之高，代替法定之据。

尤须明者，即使再审，亦非必然改判死刑立即执行。欲为此判，仍须在查明事实、正确适用法律的基础上，依法认定其罪行极其严重，且必须立即执行。刑法亦允许对符合条件的有组织暴力犯罪死缓罪犯限制减刑；能否适用，亦当以法律要件及具体情节为断。

此所以刑罚虽有轻重，而法律不可有二致也。

夫天下之民，所求于司法者，固不止于重刑一凶，尤在于明白一案，使善者知有所恃，恶者知有所畏。

若有疑而不释，则虽刑至于极，众心未必尽服；若证据明白，法律适当，虽刑非最重，亦有足以昭公信者。

故司法之公，不惟在判决之结果，尤在事实之可核、证据之可察、说理之可辨、程序之可监督。依法应予公开者当公开，依法不宜公开者亦不可以未上网一事遽断其违法；至于社会所疑之重要事实与量刑理由，凡依法可以说明者，宜尽其所能而明之。

天下之疑，不能尽以威止，惟可由理释之。

且此案所关者，又有一义。

吴恺以文章揭境外诈骗，遂遭以财募徒之害。若揭奸者不能自保，犯法者反能悬金制人，则人皆将计其言之利害，而不敢尽言其所知。如此，则为恶者益得蔽其恶，受害者益难伸其冤，国家亦将失民间揭露犯罪之一助。

故惩此类罪行，固为死者伸法，亦所以保护公众依法举报犯罪之安全。其事可生跨境有组织犯罪侵害境内社会安全之忧，然是否涉及其他特定犯罪及何人为幕后主使，仍当据证据而断，不可因其危害重大，便以未证之事充已定之罪。

昔人论治，贵在使民不畏善而畏恶。今有揭恶者遭祸，行凶者受财，则所当究者，岂止刑之缓急哉？尤当究何以使境外之恶得假手境内，何以使公权之名可为凶徒所冒，何以使揭奸之人难获周全之护。

此三者不究，虽重刑一人，后来之患未必尽绝；此三者能治，则一案之审，始可推而为长久之防。

故吾谓徽剑之案，其当严者有三：严究犯罪之组织与主使，严审定罪量刑之证据与理由，严防同类侵害之再生。

其当辨者亦有三：毋以俗称代法定之罪名，毋以赔偿掩犯罪之严重，毋以众怒代司法之判断。

至于赵冰之刑是否必须立即执行，不能但执其恶状而遽断，亦不能但举疾病、坦白、赔偿而遂止其问。应衡犯罪之全情，核从宽之实据，审死缓之法定条件，而使裁判之理由足以经受检验。

苟原判确当，则当以事实与法律明其所以当；苟原判确误，则当循法定程序正其所以误。此非专为一案求重刑，乃为天下求一不可移之准绳也。

夫法之立也，不为强者设宽，不为弱者设严；不以财多而轻其罪，不以声众而重其刑。其所断者罪，其所据者证，其所守者公。

使作恶者不能恃财而幸免，守法者不必恃势而自全；使奸人畏法，良民信法，而揭恶之言不以祸身为常。

此乃刑罚之大义，亦徽剑一案所以不可不深辨者也。